

< 2023.1학기 민소법II 중간시험문제 >

[기초사실]

X 부동산은 甲 종중의 소유인 바, 현재 X 부동산은 甲 종중 구성원인 乙, 丙, 丁의 합유로 명의신탁되어 소유권이전등기가 경료되어 있다. 그런데 乙, 丙, 丁은 아무런 근거 없이 X 부동산에 관한 소유권을 주장하고 있다.

(문제 1 및 문제 2는 상호 독립적이며 무관함)

[문제 1]

(20점)

甲 종중의 대표인 戊는 총유물에 대한 보존행위임을 주장하며, 개인 자격으로 戊 자신이 원고가 되어 乙, 丙, 丁을 상대로 X 부동산에 관한 소유권이전등기의 말소를 청구하였다. 이 경우 법원은 어떤 판결을 선고하여야 하고 그 근거는?

[문제 2]

[추가된 사실관계]

甲 종중은 乙, 丙, 丁을 상대로 명의신탁계약을 해지하고 X 부동산에 관한 이들 명의의 소유권이전등기의 말소를 구하는 소송을 제기하였다.

[문제 2 -1]

(10점)

甲 종중은 乙, 丙, 丁이 답변서를 제출하기 전(제1회 변론기일이 열리기 전이다) 바로 소를 취하하였는데, 乙, 丙, 丁은 위 소취하에 대하여 부동의 취지의 의견서를 법원에 제출하였다. 甲 종중의 소취하의 효력은?

[문제 2-2] (문제 2-1과 달리)

(20점)

만약 제1심에서 전부패소한 원고(甲 종중)의 항소로 인한 항소심 소송계속중 甲 종중이 乙, 丙, 丁에 대한 위 말소청구의 소를 취하하였고, 그 후 甲 종중이 별도로 乙, 丙, 丁을 상대로 X 부동산에 관한 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구의 소를 제기하였다. 이 경우 법원은 어떤 판결을 선고하여야 하고 그 근거는?

甲은 2020. 8. 1. 乙과의 사이에서 乙로부터 乙 소유인 X토지를 금 3억 원에 매수하는 내용의 매매계약을 체결하였다. 甲은 “2020. 10. 1. 위 매매계약에 따라 乙에게 매매대금을 모두 지급하였는데, 乙이 이런저런 핑계를 대며 소유권이전등기절차이행을 미루고 있다”고 주장하면서, 2020. 12. 1. 乙을 상대로 X토지에 관하여 위 매매를 원인으로 한 소유권이전등기절차의 이행을 구하는 소송을 제기하였다. (※ 아래 각 지문은 상호 독립적이며 무관함)

[문제 3]

甲은 위 소송에서 2020. 8. 1.자 매매계약서를 증거로 제출하였는데, 乙은 “위 매매계약서는 甲과 乙이 작성한 것은 맞으나, 위 매매계약은 통정허위표시로서 무효이다”라는 내용의 답변서를 제출하였다. 2021. 3. 5. 제1회 변론기일에 甲은 출석, 乙은 불출석하였으나, 법원은 피고가 제출한 답변서를 진술한 것으로 간주하고서 1회 변론기일을 진행하였다. 그런데 乙은 그 후 “위 매매계약서는 위조된 것이다”라는 내용이 담긴 2021. 3. 15.자 준비서면을 제출하였고 2021. 4. 3. 제2회 변론기일에 甲과 乙이 모두 출석하여 변론이 진행되었다. 이러한 경우 법원이 위 매매계약서를 甲의 청구를 뒷받침하는 증거로 사용할 수 있는지 그 여부에 관하여 설명하라. (30점)

[문제 4]

위 소송에서 乙은 매매계약이 실효되었다고 주장하면서, 예비적 항변으로서 “만일 위 매매계약이 유효하다면, 乙은 甲으로부터 잔금을 지급받지 못하였으므로 甲의 잔금 지급과 상환으로 소유권이전등기절차를 이행할 의무가 있다”고 주장하였다. 甲은 乙의 위 주장에 대하여 “乙에 대한 대여금채권으로 위 잔금채권과 대등액에서 상계한다”는 상계재항변을 하였다. 법원은 판결이유에서 “위 매매계약은 유효하지만 甲 주장의 대여금채권이 인정되지 않는다”는 판단을 하면서, 이에 따라 “乙은 甲으로부터 잔금을 지급받음과 동시에 甲에게 X토지에 관한 소유권이전등기절차를 이행하라”는 판결을 선고하였고 위 판결은 그대로 확정되었다. 그 이후 이번에는 甲이 乙을 상대로 위 대여금을 지급하라는 소송을 제기하였는데, 그 소송에서 乙은 “甲 주장의 대여금 채권은 전소 확정판결의 기판력에 저촉된다”고 항변하였다. 이 항변에 대하여 법원은 어떻게 판단하여야 하는가? (20점)

<답안>

[문제 1]

답 : 법원은 당사자적격 흠결을 이유로 소각하 판결을 하여야 한다.

이유 또는 근거 :

민법 제276조 제1항은 "총유물의 관리 및 처분은 사원총회의 결의에 의한다.", 같은 조 제2항은 "각 사원은 정관 기타의 규약에 좇아 총유물을 사용·수익할 수 있다."라고 규정하고 있을 뿐 공유나 합유의 경우처럼 보존행위는 그 구성원 각자가 할 수 있다는 민법 제265조 단서 또는 제272조 단서와 같은 규정을 두고 있지 아니한바, 이는 법인 아닌 사단의 소유형태인 총유가 공유나 합유에 비하여 단체성이 강하고 구성원 개인들의 총유재산에 대한 지분권이 인정되지 아니하는 데에서 나온 당연한 귀결이라고 할 것이므로 총유재산에 관한 소송은 법인 아닌 사단이 그 명의로 사원총회의 결의를 거쳐 하거나 또는 그 구성원 전원이 당사자가 되어 필수적 공동소송의 형태로 할 수 있을 뿐 그 사단의 구성원은 설령 그가 사단의 대표자라거나 사원총회의 결의를 거쳤다 하더라도 그 소송의 당사자가 될 수 없고, 이러한 법리는 총유재산의 보존행위로서 소를 제기하는 경우에도 마찬가지라 할 것이다.

(2004다44971)

[문제 2-1]

소취하는 유효하다(민소법 266조 1항, 2항을 적시하면 됨).

[문제 2-2]

답 : 재소금지 원칙에 따라 법원은 후에 제기된 소에 관해 소각하 판결을 하여야 한다.

근거:

진정한 등기명의를 회복을 위한 소유권이전등기청구는 이미 자기 앞으로 소유권을 표상하는 등기가 되어 있었거나 법률에 의하여 소유권을 취득한 자가 진정한 등기명의를 회복하기 위한 방법으로 현재의 등기명의인을 상대로 그 등기의 말소를 구하는 것에 갈음하여 허용되는 것인데, 말소등기에 갈음하여 허용되는 진정한 명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구권과 무효등기의 말소청구권은 어느 것이나 진정한 소유자의 등기명의를 회복하기 위한 것으로서 실질적으로 그 목적이 동일하고, 두 청구권

모두 소유권에 기한 방해배제청구권으로서 그 법적 근거와 성질이 동일하므로, 비록 전자는 이전등기, 후자는 말소등기의 형식을 취하고 있다고 하더라도 그 소송물은 실질상 동일한 것으로 보아야 하고, 따라서 소유권이전등기말소청구소송에서 패소확정 판결을 받았다면 그 기판력은 그 후 제기된 진정명의회복을 원인으로 한 소유권이전등기청구소송에도 미친다.

(대법원 2001. 9. 20. 선고 99다37894 전원합의체 판결)

[문제3] (30점)

1. 문제의 소재(쟁점) : 서증의 진정성립 인정에 관한 구속력, 자백의 철회(철회) - 3점
2. 변론기일 불출석의 효과(진술간주를 통한 서증 진정성립 인정에 관한 구속력) - 10점
 - 원고인 갑이 출석하고 피고인 을이 불출석하여 재판부가 변론기일을 그대로 진행한 경우, 피고가 제출하여 원고에게 송부된 답변서는 진술간주됨. 따라서 을의 답변서가 진술간주됨으로써 매매계약서의 진정성립을 인정하는 진술이 이루어진 것으로 간주됨
 - 재판상 자백은 주요사실에 대하여 인정되고 간접사실이나 보조사실에 대하여는 적용되지 않는 것이 원칙
 - 다만 대법원은 서증의 진정성립 여부는 보조사실에 해당하지만 상대방이 이를 인정할 경우 예외적으로 재판상 자백이 성립된 것과 마찬가지로의 구속력이 인정된다고 보고 있음
 - 사안에서 진술간주를 통한 매매계약서에 대한 을의 진정성립 인정에는 재판상 자백과 같은 구속력이 인정됨
3. 을의 진술 반복의 효과(자백 철회)의 가능 여부) - 12점
 - 을이 매매계약서가 위조된 것이라고 주장하는 것은 서증의 진정성립에 관한 자백을 철회하는 취지의 진술
 - 을의 자백이 철회되기 위해서는 ① 갑 등이 이에 동의하거나, ② 자백이 제3자의 형사상 처벌할 행위에 의하여 이루어졌음을 을이 주장, 증명하거나, ③ 자백이 진실에 반하고 착오로 인한 것이었다는 점을 을이 주장, 증명하여야 함
 - 위 철회의 요건을 충족시킴으로써 매매계약서의 진정성립에 관한 자백이 적법하게 취소된다면 매매계약서의 제출자인 갑이 그 진정성립을 증명할 책임을 지게 됨.
4. 결론(사안의 해결) - 5점
 - 사안에서 을이 매매계약서의 진정성립이 진실에 반하고 착오로 진정성립을 인정하였다는 점

1) 자백 철회 또는 자백 취소

등 위 ① 내지 ③ 요건을 증명하지 못할 경우, 법원은 종전의 을의 진술(자백)에 구속되어 매매계약서의 진정성립을 인정하여야 하므로 이를 증거로 사용할 수 있음. 반대로 을이 위 철회의 요건이 충족되었음을 증명하지 못할 경우에는 갑이 매매계약서의 진정성립을 증명하지 못한다면 법원은 이를 증거로 사용할 수 없음.

[문제4] (20점)

1. 문제의 소재(쟁점) : 기판력의 객관적 범위, 상계항변에 제공된 채권에 대하여 기판력이 인정되는 범위 - 2점
2. 기판력의 객관적 범위 - 7점
 - 판결주문에서 한 판단에 한하여 기판력이 인정되며(제216조 제1항), 판결이유 중의 항변사항에 대해서는 그것이 판결주문의 결론을 내리는 기초가 되었다 하더라도 기판력이 생기지 않음
 - 다만 상계항변은 예외. 피고가 상계항변을 제출하고 법원이 자동채권의 존부에 관하여 판결이유에서 판단하였을 경우에는 상계로써 대항한 액수의 한도 내에서 기판력이 발생함(제216조 제2항).
 - 판결이유 중의 판단임에도 상계 주장에 관한 법원의 판단에 기판력을 인정할 취지
3. 상계항변의 경우 기판력의 인정 범위 - 8점
 - 자동채권의 존부에 관하여 실질적인 판단이 있었을 것
 - : 상계항변의 실기각하, 상계금지, 상계부적상 등의 이유로 상계항변이 배척된 경우에는 기판력이 발생하지 않음. 상계로써 대항한 액수에 한하여 기판력 발생
 - 수동채권이 소송물로서 심판의 대상일 것
 - : 대법원 2005. 7. 22. 선고 2004다17207 판결의 결론 및 취지
4. 사안에의 적용 및 결론 - 3점
 - 갑 주장의 대여금채권의 부존재에 기판력 발생하지 않으므로 후소에서 이와 다른 주장 가능, 따라서 갑의 후소에서의 청구가 전소 확정판결의 기판력에 저촉된다는 을의 항변은 타당하지 않음 (그러나 전소확정판결이유에서 판단된 위 대여금채권 부존재 사실이 후소에서 이를 채용할 수 없는 특별한 사정이 없는 한 유력한 증거자료가 되므로, 후소법원은 특별한 사정이 없는 한 청구 기각판결을 해야 할 것임)